

1501702-28.2019.8.26.0102

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... do TJSP:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. Pretensão de reforma, quanto a cada um dos ilícitos, e substituição da reprimenda. Parcial possibilidade. 1. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade demonstradas.

Depoimento dos policiais. Meio seguro de prova. Precedentes. 2. Associação para o tráfico. Dolo associativo não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Cachoeira Paulista-SP - cep 12630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501702-28.2019.8.26.0102 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501702-28.2019.8.26.0102

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2343084/2019 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 5442550 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 1357/19/210 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 2343084 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 1357/19/210 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KESLENY LUIZ FELIZARDO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra KESLENY LUIZ FELIZARDO SOUZA pela suposta prática das condutas prevista nos artigos 34 e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em sua denúncia fls. 1-4, o Parquet alegou que:

[...]Consta do incluso autos de inquérito policial que, no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 14 horas e 40 minutos, na Rua Joaquim Santos Pinto, n.º 27, Centro, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, KESLENY LUIZ FELIZARDO SOUZA,

qualificado às fls.07, possuía e guardava, ainda que gratuitamente, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais de fls.11/18.

Consta, ainda, que nas mesmas condições espaciais e temporais, KESLENY LUIZ FELIZARDO SOUZA, qualificado às fls.07, associou-se a duas ou mais pessoas, ainda não identificadas, para praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, e 34 da Lei n.º 11.343/06.

Segundo o apurado, policiais militares receberam informação no sentido de que o denunciado armazenava em sua residência entorpecentes, além de armas de fogo. Desse modo, dirigiram-se para o local indicado e o denunciado franqueou a entrada no imóvel. Na sequência, Kesleny indicou aos policiais que armazenava em sua residência objetos que constituem instrumentos que eram destinados à preparação, produção e transformação de entorpecentes.

Com efeito, os policiais localizaram em uma mochila 284 (duzentos e oitenta e quatro) microtubos contendo resquícios de cocaína, 6 (seis) sacolés plásticos e 8 (oito) potes de fermento "Pó Royal".

Na localidade, o Kesleny confessou informalmente aos policiais que recebia o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) por semana para guardar entorpecentes, bem como para ceder o local para a preparação de entorpecentes. O denunciado esclareceu, ainda, que no dia anterior, indivíduos, os quais não quis identificar por temer represarias, estiveram em sua residência e levaram grande quantidade de cocaína e um "tijolo" de maconha.

É certo que os objetos apreendidos foram submetidos a estudo pericial e constatou-se que "as peças examinadas correspondem a 284 unidades de microtubos de polipropileno para centrifugação, graduados ou não graduados, dotados de tampo e translúcidos nas cores azul, laranja, transparente, lilás, rosa e verde. Possuíam resquícios de substância pulverulenta bege em seu interior, a qual foi submetida a exame preliminar nesse Instituto de Criminalística, resultando positivo para cocaína. Estes microtubos, fabricados por empresas diversas e conhecidas popularmente como tubos ou microtubos de eppendorf, tem seu uso principal direcionado às atividades laboratoriais. Todavia, tem sua função original atualmente desviada para a prática de tráfico de entorpecente, sendo eficazmente utilizado para acondicionamento de tais substâncias" (fls.11/14).

Ainda que "apenas o teste realizado neste Instituto não pode precisar qual a substância nos potes, entretanto, como diversas substância em pó na cor branca, pode ser utilizada como diluente no preparo de substância entorpecentes" (fls.15/18).

Por fim, interrogado em solo policial o denunciado confessou que o imóvel de sua propriedade era para que traficantes guardassem e refinassem entorpecentes para posterior revenda.[...]

As fls.15/18 e 19/22 foram acostados laudos periciais.

Em 29 de abril de 2021 foi recebida a denúncia (fls.74/75).

Citado pessoalmente (fl.85), o réu ofereceu resposta à acusação (fl.107)

Na audiência de instrução e julgamento (fls.145 e 150) procedeu-se a oitiva das testemunhas, e interrogatório do réu.

Em alegações finais (fls.156/162), o MP requereu a parcial procedência do pedido.

Em alegações finais (fls.168/172), a defesa requereu a absolvição do réu.

É o relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Do crime do art. 34, caput, da Lei de Drogas

Da autoria e da materialidade

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras,

são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Visando a comprovação desta têm-se nos autos: boletim de ocorrência nº 1357/2019 (fls.07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls.09/10), pelo laudo de constatação (fls.15/22).

Ainda, a prova oral foi colhida no seguinte sentido:

A testemunha Paulo Eduardo Mendes Maciel disse em juízo que: recebeu denúncias no sentido que o acusado estava mantendo em sua residência materiais ilícitos, como entorpecentes e armas; afirma que o réu franqueou a entrada dos policiais e confessou que detinha na mochila pinos de cocaína; ao ser localizada a mochila foi constatado 284 pinos de cocaína com resquícios de droga e potes de pó royal com resquícios também; afirma que o acusado confessou a trafica da mercancia ilícita e que no dia anterior teria ido pessoas até sua residência retirar produtos ilícitos; afirmou que o acusado já era conhecido pela prática da mercancia.

A testemunha Luís César Franklin disse em juízo que: receberam denúncias que o acusado estaria guardando armas e drogas em sua casa, assim os policiais foram até lá; chegando lá o réu confessou o crime e mostrou onde estavam os objetos, afirmando que não pertenciam a ele e que recebia um valor de 300 reais para manutenção da droga na sua residência, e que no dia anterior haviam ido pessoas até sua casa retirar os materiais ilícitos; afirma que conhece o réu por este possuir condenação pelo delito de roubo, e disse que o réu foi preso em flagrante com outro indivíduo por tráfico e associação; afirmou que detinham a informação eu o réu residia naquele local; por fim, disse que no dia dos fatos o réu não foi preso mas posteriormente teria sido indiciado, durante as investigações.

A testemunha Vinicius da Silva Santos disse em juízo que: receberam uma denuncia anônima de que o acusado estaria guardando em sua casa entorpecentes e armamentos; ao chegar no local, o réu confessou os fatos e autorizou a entrada dos policiais, indicando os objetos; disse que o acusado confessou que até o dia anterior sua residência era utilizada para preparação e depósito das drogas, disse que recebia 300 reais para guardar os entorpecentes; afirma que levaram o réu para delegacia para proceder com o boletim de ocorrência.

Em interrogatório, o réu KESLENY LUIZ FELIZARDO SOUZA disse em juízo que: trocava os pinos por drogas, pois era usuário; não alugava sua residência para o tráfico; disse que no dia dos fatos viu os policiais batendo em seu portão, concedeu-os a entrada e mostrou os objetos aos policiais.

No caso concreto não há elementos para configurar a tipificação prevista no artigo 34 da lei 11.343/2006, eis que o acusado detinha em sua mochila 284 pinos de eppendorfs vazios com resquícios de cocaína conforme laudo às fls.15-18, e um pote da marca royal, conforme auto de apreensão e exibição às fls.9/10.

Ressalta-se que a posse dos utensílios acima descritos não tipifica o delito em questão, conforme artigo abaixo transcrito.

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Fato este que não permite afirmar que destinavam especificadamente à fabricação, preparação ou transformação de drogas, nos moldes o fim específico tipificado no artigo acima.

Ainda que os pinos de eppendorfs sejam comumente utilizados para embalagem de drogas, esta não se confunde com os conceitos de e fabricar, preparar, produzir ou transformar drogas, os quais devem ter seu significado extraído a partir de uma interpretação estrita, como corolário do princípio da legalidade.

Nesse sentido, conforme o doutrinador Renato Brasileiro Lima:

“produção em larga escala”; preparação significa a “obtenção de algo por meio da composição de elementos”; produção é “manufaturar ou fazer surgir em menor escala” e, por derradeiro, transformação traduz-se na “alteração da composição original” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 7 ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1216.)

Assim, os pinos encontrados na posse do réu, conforme acima exposto, destinavam-se

à distribuição e embalos de entorpecentes já previamente preparados, para venda, fim este que não se enquadra ao tipo penal em questão.

Desse modo, conforme o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos análogos:

MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que os materiais apreendidos são drogas (maconha, cocaína e crack).AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de droga em poder dos réus e do menor validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros quantidade e variedade, incomum com a figura do usuário; apreensão de dinheiro, balança de precisão e material para embalagem de rigor a condenação dos réus provimento ao recurso ministerial. CAUSA DE AUMENTO prática do delito que envolveu adolescente causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ausência de prova de estabilidade e permanência de rigor a absolvição improvimento ao apelo ministerial. PETRECHOS DE FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES insumo químico utilizado como precursor para fabricação e síntese de entorpecentes apreensão de facão, tesoura, balança de precisão e embalagens vazias petrechos e insumo que não integra a descrição do tipo atipicidade de rigor a absolvição improvimento para este fim. [...] (TJ-SP- APR:15017475920178260536 SP 1501747-59.2017.8.26.0536, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 06/10/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020) (grifos nossos)

PRELIMINAR ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO caso em que se adentrou a residência em situação de flagrante delito uma das hipóteses garantida pela Constituição Federal ocultação de drogas no interior da casa delito permanente constante o estado de flagrante busca e apreensão amparada em fundadas suspeitas, já que os policiais puderam confirmar denúncias anônimas ao constatarem o réu que reunia as características físicas declinadas saindo de local também indicado na denúncia como sendo o imóvel onde eram guardadas as armas e drogas inexistência de ilegalidade lícitude da diligência realizada lícitude das provas colhidas em face do flagrante preliminar afastada. PETRECHOS DE FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES balança e embalagens vazias não integra a descrição do tipo atipicidade de rigor a absolvição -provimento para este fim. TRÁFICO MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. [...]. (TJ-SP 00355998820168260050 SP0035599-88.2016.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 10/05/2018, 12ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/05/2018). (grifos nossos)

Diante do exposto, o réu deve ser absolvido com base no art. 386, VII, do CPP.

II.2 Do crime do art. 35 da Lei de Drogas

Da autoria e da materialidade

O art. 35 da Lei de Drogas tipifica a conduta de “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”.

A doutrina faz as seguintes considerações sobre o tipo penal:

“101. Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. (...).

101-A. Desnecessidade de laudo toxicológico: o crime de associação é formal, voltando-se contra o bem jurídico primário consubstanciado na paz pública. Logo, torna-se desnecessário apreender a droga ou examiná-las. A materialidade pode dar-se por qualquer outro meio lícito. (...)

(...)

103. Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do crime do art. 35 (...) é fundamental que os sujeitos se reúnam com

o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, vol. 1, p. 436/439) (grifos acrescentados)

O entendimento consolidado no STJ é o de que a incidência desse tipo penal exige certa estabilidade e permanência:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO QUE SEMOSTRA DEVIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART.33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.

REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

No caso, as instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os pacientes e os integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho; na verdade, as instâncias de origem presumiram, com base apenas no local em que os réus foram presos em flagrante, que eles seriam integrantes do Comando Vermelho e, assim, proclamaram a condenação destes com base em meras conjecturas acerca de uma *societas sceleris*.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte *objecti*, quer a parte *subjecti*. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva ? o ânimo a mover a conduta ?, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez afastada a condenação dos pacientes pelo crime de associação ao tráfico e porque eles são tecnicamente primários, possuidores de bons antecedentes e não há, nos autos, elementos concretos a evidenciar sua dedicação a atividades delituosas ou integração a organização criminosa, deve ser aplicada, em favor, dos dois a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Como consectário da redução efetivada na pena dos acusados, deve ser feito o ajuste no regime inicial do seu cumprimento das respectivas penalidades para o semiaberto, pois, apesar de terem sido condenados a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, serem tecnicamente primários ao tempo do delito e, possuidores de bons antecedentes, tiveram a pena-base estabelecida acima do mínimo legal.

Ordem concedida, para absolver os pacientes pela prática do crime previsto no art.35 da Lei n. 11.343/2006, reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art.33 da Lei n. 11.343/2006 e aplicá-la no patamar máximo de 2/3.(HC 596.389/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021)1 (grifos acrescentados)

É esse também o entendimento do TJSP:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. Pretensão de reforma, quanto a cada um dos ilícitos, e substituição da reprimenda. Parcial possibilidade. 1. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade demonstradas.

Depoimento dos policiais. Meio seguro de prova. Precedentes. 2. Associação para o tráfico. Dolo associativo não demonstrado. Concurso de pessoas, eventual ou permanente, que não se confunde com a figura do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Precedentes. Sentença alterada, neste ponto. Improcedência da representação. 3. Internação. Cabimento. Interpretação extensiva das hipóteses anotadas no art. 122 do ECA. Gravidade da conduta. Condições pessoais desfavoráveis. Necessidade de afastamento do meio deletério. Proposta sócio educativa intensificada. Atendimento do critério da excepcionalidade (art. 122, § 2º, do ECA). Precedentes. Sentença

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1515532-05.2020.8.26.0562;

Relator (a): Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santos - Vara

da Infância, Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 04/10/2021; Data de Registro: 04/10/2021) (grifos acrescidos).

No caso concreto, não há nos autos nada que demonstre de forma cabal o vínculo associativo entre o acusado e outros indivíduos, conforme exposto pelo próprio membro do Ministério Público em alegações finais.

Assim, não há prova suficiente para a condenação.

Como se sabe, a condenação criminal exige um grau muito elevado de probabilidade quanto às alegações de fato, a ponto de haver o dever de absolver quando não há provas ou quando existe uma dúvida razoável em favor do acusado:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV- estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V- não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI- existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII- não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:

I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;

II- ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

III - aplicará medida de segurança, se cabível. (grifos acrescidos)

Desta forma, o réu deve ser absolvido com base no art. 386, VII, do CPP.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para ABSOLVER o réu KESLENY LUIZ FELIZARDO SOUZA dos delitos previstos nos artigos 34 e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, com base no art. 386, VII, do CPP. Fixo os honorários advocatícios do(s) patrono(s) de acordo com a tabela do convênio celebrado entre a OAB/DPE. Expeça(m)-se certidão(ões) a qual ficará disponível através do sistema SAJ para que o advogado, após a devida conferência, providencie sua impressão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cachoeira Paulista, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA